

1501220-55.2018.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
GILBERTO WENDER ROSAS DE MORAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GILBERTO WENDER ROSAS DE MORAES, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
4ª Vara Criminal
Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501220-55.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501220-55.2018.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
GILBERTO WENDER ROSAS DE MORAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GILBERTO WENDER ROSAS DE MORAES, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 142/144) que, no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 11h12min, na Rua Cuiabá, nº 1017, Rochdale, nesta cidade e Comarca de Osasco, GILBERTO WENDER ROSAS DE MORAES, qualificado às fls. 13/14, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de venda para consumo de terceiros, trazia consigo drogas, consistentes em 11 (onze) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", no total de 1,8g (um grama e oito

centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, contendo 1,2g (um grama e dois centigramas) e a quantia de R\$ 64,25 (sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 09 e laudo de exame químico-toxicológico às fls. 136/138.

Narra, ainda, a inicial acusatória, que, segundo se apurou, na data do ocorrido, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o denunciado e mais dois indivíduos, EDSON PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO GARCIA DUVAIZEM, numa viela.

Na ocasião, GILBERTO realizava anotações em um papel, alusivas à contabilidade das vendas. Os policiais abordaram os três indivíduos e com GILBERTO continuou andando fingindo não ouvir, contudo, foi detido um metro a frente.

Em revista pessoal, localizaram com GILBERTO os entorpecentes e a quantia em dinheiro descritos acima, ao passo que com EDSON localizaram uma pedra de crack e com CRISTIANO nada de ilícito foi localizado. Diante disso, foi dada voz de prisão aos três indivíduos e todos conduzidos à Delegacia de Polícia.

Interrogado, GILBERTO alegou ser usuário de substâncias entorpecentes e afirmou ter entregado uma porção de crack para EDSON, o qual é usuário de drogas e seu amigo de longa data. A forma de acondicionamento das drogas, a quantidade de entorpecentes e as demais circunstâncias do fato criminoso, bem como a confissão de GILBERTO de ter entregado gratuitamente "crack" a EDSON, demonstraram que as drogas se destinavam ao tráfico de entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01. Em sede de audiência de custódia, foi concedida ao réu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão (fls. 78/80). Alvará de soltura cumprido às fls. 91/92.

Auto de exibição e apreensão às fls. 9. Fotografias dos bens apreendidos às fls. 28/30 e 34/35.

Laudo de constatação às fls. 31/33 e definitivo às fls. 136/138.

Notificado às fls. 158/159, o réu apresentou defesa prévia às fls. 163.

A denúncia foi recebida às fls. 169.

Embora realizada audiência de instrução às fls. 217/220, ocasião em que foi decretada a revelia do acusado, constatou-se, posteriormente, que, aplicado o rito especial da Lei de Drogas, o réu não havia sido citado para a audiência (fls. 229).

Com isso, o Ministério Público requereu a reconsideração da decretação da revelia do acusado e a designação de nova audiência, dessa vez com a citação pessoal do réu, nos endereços apresentados pela Acusação (fls. 234 e 236/239).

Assim, foi designada nova audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 09.05.2022 às 16:30 horas (fls. 240), a qual, todavia, não se realizou e, portanto, foi redesignada para o dia 07.11.2022, às 16:00 horas (fls. 267).

O réu foi citado às fls. 246 e constituiu Defesa às fls. 264/265.

Folha de antecedentes às fls. 285/306.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em debates a acusação pediu a procedência nos termos da inicial.

Em debates a defesa pediu a desclassificação. Em caso de condenação o reconhecimento do privilégio.

É relatório.

Fundamento e decido

Valoração probatória de autoria e materialidade

É caso de desclassificação da conduta narrada na inicial.

Consto, inicialmente, que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a reponsabilidade penal da réu consistente na conduta típica de trazer consigo destinadas ao consumo de terceiros. Não logrou o Ministério Público superar a presunção constitucional para além de qualquer dúvida objetivamente razoável.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 136/138).

Quanto a imputação de autoria, nada há nos autos, de concreto, a indicar o tráfico, mas sim ilações do Ministério Público, até porque os policiais não relataram de forma harmônica qualquer conduta do réu de trazer drogas destinadas a terceiros e, ainda, inseriram informações não constantes dos autos, sem contar que o policial Fernando foi enfático ao dizer que o réu afirmou que lá estava para consumir drogas.

O réu, ouvido em juízo, afirmou que estava no local usando droga, juntamente com seus amigos. Seus dois amigos foram abordados em primeiro lugar. Após sair do local também foi abordado. Foi encontrada uma quantidade de droga que era para seu consumo. Desconhece anotações de tráfico. Afirmou que cada um estava utilizando sua própria droga. Já foi internado em uma clínica em Jundiaí, por ser dependente, e esta "livre" das drogas há dois anos.

Pois bem. Não logrou o Ministério Público produzir provas que fossem suficientes a afastar o postulado da presunção de inocência quanto a crime de tráfico.

Em primeiro lugar, anoto que a premissa fática do Ministério Público é que em revista pessoal, localizaram com GILBERTO os entorpecentes e a quantia em dinheiro descritos acima não tem qualquer amparo probatório. O policial Rodrigo, ouvido em juízo, afirmou que "um rapaz saiu andando e dispensou droga e anotação." Acredita que este "rapaz" seja o réu. Afirmou que, no momento, o réu declarou que era usuário e que a droga era para seu consumo. O policial Fernando Henrique, por outro lado, relatou que viu o réu "com dois rapazes". O réu, ao ver os policiais dispensou algo no chão. Encontraram uma porção de droga, uma caneta e anotação. Afirmou que no momento o réu disse que a anotação era do jogo do bicho, a droga para consumo e o dinheiro havia ganho no Ceasa. Ambos os policiais não se recordaram do réu.

Com efeito, dos autos a única certeza é o encontro das drogas com o réu. E este encontro, frise-se, é baseado na confissão do acusado de que a droga era para seu

consumo pois a versão dos policiais é dissonante em relação a premissa do Ministério Público eis que, na inicial, afirma o Ministério Público que a droga e anotações foram apreendidas com o réu após revista. Já os policiais afirmam que encontraram após serem dispensadas. De todo modo, até pela pequeníssima quantidade de entorpecente, não há provas de que as drogas se destinavam ao consumo de terceiros.

Em segundo lugar, os policiais não presenciaram ato de traficância, inclusive um dos rapazes que lá estava foi conduzido sem ter consigo nada de ilícito. Em terceiro lugar, a versão do réu de que era dependente está em sintonia com o afirmado pelos policiais eis que, no momento, ambos afirmam que o réu declarou ser usuário de droga.

A única certeza dos autos, portanto, é o encontro da droga, sendo que seu destino permanece obnubilado. Qualquer tentativa de reconhecimento da conduta de tráfico, em qualquer de seus verbos núcleo típicos, seria meras presunções e é despiciendo afirmar que o direito penal não aceita presunções de culpa. Anote-se que o réu é primário. Não possui antecedentes e, segundo declarou, está regularmente empregado.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria (ou presunções, como afirmado). A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo concreto produzido em contraditório judicial. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Nesse sentido, levando-se em conta o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, verifica-se que a imputação contida na denúncia, vale dizer, os fatos criminosos nela narrados, dos quais o réu se defendeu, impõe uma nova definição jurídica, ou seja, os fatos descritos se subsomem ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas, e não ao tipo da capitulação feita na inicial. Não houve qualquer alteração fática, pois o fato criminoso continua o mesmo, o que deve ser alterado é tão-somente sua definição jurídica.

Diante do exposto, nos termos do art. 74, § 2º e art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o fato criminoso imputado ao réu na denúncia para o art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, DECLARO este juízo incompetente para a apreciação do pedido e, assim, DETERMINO, após o trânsito em julgado, a redistribuição do feito ao Juizado Especial Criminal, para que seja observado o procedimento da Lei n. 9099/95.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

PRIC

Osasco, 07 de novembro de 2022.